

O REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Wilson José Vinci Júnior

Mestre e doutorando em Direito pela PUC/SP. Procurador Federal.

Resumo: O presente artigo versa sobre o regime jurídico dos direitos fundamentais. Será analisado se é possível afirmar que esse regime jurídico segue normas próprias ou, ao revés, se ele pode ser considerado uma espécie de regime jurídico, puramente de direito público ou de direito privado. Para tanto, serão fornecidos os conceitos de direitos fundamentais e de regime jurídico, além de outros indispensáveis ao entendimento do tema, a exemplo da definição de direitos humanos, princípios jurídicos e função contramajoritária dos direitos fundamentais.

INTRODUÇÃO

Atualmente, muito se tem falado sobre os direitos fundamentais. Artigos jurídicos e reportagens jornalísticas são escritas diuturnamente sobre essa temática. Todavia, não se ouve falar na mesma intensidade sobre o regime jurídico aplicável aos direitos fundamentais.

A importância do tema reside no fato de que é indispensável saber como os direitos fundamentais incidirão em um caso concreto. De nada adianta proclamar que determinado direito fundamental é aplicável em um certo caso se não se sabe a maneira como tal ocorrerá. É justamente isso que pretende o presente artigo: fomentar o debate acerca do regime jurídico dos direitos fundamentais, ou seja, saber a quais normas jurídicas os direitos fundamentais estão sujeitos.

O artigo está estruturado, inicialmente, apresentando a historicidade dos direitos fundamentais, para em seguida fornecer a conceituação tanto de direitos fundamentais como de regime jurídico. Após, serão explicadas as particularidades que permitem afirmar que os direitos fundamentais seguem um regime jurídico próprio sendo que, ao final, será apresentada a conclusão do estudo.

Evidentemente, não se pretende esgotar a análise da matéria, até por uma impossibilidade física de fazê-lo em um artigo jurídico. Porém, a proposta é justamente fomentar o debate para que, cada vez mais, a temática seja discutida e aprofundada, gerando segurança jurídica na análise do regime jurídico aplicável aos direitos fundamentais.

HISTORICIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Para se estudar um assunto tão relevante como os direitos fundamentais, nada melhor do que iniciar a análise de como eles surgiram. Saber o contexto histórico do surgimento de dado instituto, auxilia na sua compreensão, além de fornecer base sólida para a aplicação presente e, quiçá, noções para o seu desenvolvimento futuro.

Historicamente, os direitos fundamentais surgiram como forma de se limitar o abuso do poder estatal. É de se recordar que, na época das monarquias absolutistas, o rei era considerado um representante de Deus na Terra, sendo que Deus representava uma autoridade superior aos seres humanos que irradiava a perfeição. Logo, como Deus não cometia erros, o monarca, seu representante no mundo fático, igualmente não errava (*the king can do no wrong*), de maneira que as suas decisões não poderiam ser questionadas pelos súditos, sob o argumento de que, caso o fossem, em verdade era Deus que estaria sendo contrariado. Em uma época onde a influência religiosa no Estado era extremamente acentuada e onde o povo ainda não era o verdadeiro titular do poder estatal, não se exige uma maior reflexão para saber que as ordens do monarca deveriam ser cumpridas sem maiores delongas.

Ocorre que a filosofia ensina que todo ser humano tende a abusar do poder que lhe é conferido. Assim, com o passar do tempo, a sociedade passou a enfrentar as agruras de ter de suportar infundados caprichos do “*governante de ocasião*”, os quais, por vezes, traziam sofrimentos desnecessários aos indivíduos.

Portanto, o poder estatal, que é o poder de determinar o comportamento dos indivíduos visando ao bem comum, estava sendo desvirtuado para determinar o comportamento dos indivíduos visando unicamente ao atendimento da vontade pessoal do monarca, vontade essa muitas vezes injustificada sob um ponto de vista lógico-racional. Era preciso, pois, frear o abuso na utilização desse poder estatal.

Houve a criação, então, de várias maneiras de se controlar o poder estatal, visando à atenuação do seu abuso, dentre as quais podem ser citadas a tripartição das funções do poder estatal (em executiva, legislativa e judiciária), o surgimento das constituições dos Estados modernos, tal qual se conhece atualmente (documento que está acima da vontade pessoal dos governantes) e a inserção, nessas constituições, dos denominados “direitos fundamentais”.

Assim, com as constituições americana de 1787 e francesa de 1791, surge o chamado constitucionalismo contemporâneo, movimento pelo qual a constituição foi erigida ao patamar de superioridade jurídica em um ordenamento. Agora, acima da vontade pessoal do governante, existe a vontade do povo, verdadeiro titular do poder, estampada em um documento com força jurídica vinculante denominado “*constituição*”. Para Canotilho¹²⁶, “*constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade*”.

E, nesse documento denominado “constituição”, foram inseridos diversos assuntos, dentre os quais a previsão dos chamados direitos fundamentais, que serão melhor explicitados no tópico posterior. Porém, desde já convém explicar que, segundo o jurista alemão Robert Alexy, diversos assuntos foram previstos em uma constituição (dentre eles a temática dos direitos fundamentais), justamente para se evitar a sua regulamentação pela chamada “maioria legislativa de ocasião”. Assim, tendo em vista que o constituinte “desconfia” do legislador ordinário, é de bom alvitre que se constitucionalize alguns assuntos (dentre eles, os direitos fundamentais), para que não se deixe margem para que o legislador ordinário decida se quer reconhecê-los ou não. Em estando previstos em uma constituição, cabe ao legislador ordinário implementá-los, não podendo negligenciar essa imposição constitucional. Nas palavras do jurista alemão, “*como ninguém conhece o legislador futuro e também as circunstâncias sob as quais ele agirá, ninguém pode ter certeza de que ele não utilizará [...] aquelas liberdades e competências de forma desfavorável aos indivíduos*”.¹²⁷ O fato dos direitos fundamentais estarem constitucionalizados também os imuniza contra a ação de eventual maioria legislativa de ocasião, exsurindo a

126 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e teoria da constituição*. 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2016, p. 51.

denominada função contramajoritária dos direitos fundamentais que protege o indivíduo em face da vontade da maioria das pessoas, a qual, não necessariamente, é coincidente com a proteção conferida pelos direitos fundamentais. Vale dizer: o constituinte originário realiza uma autolimitação do poder do próprio povo, justamente para proteger esse mesmo titular do poder de eventuais momentos de fraqueza futura.

Aliás, cabe ressaltar que os direitos fundamentais não são propriamente “criados” pelo Poder Legislativo, mas sim são *reconhecidos* expressamente por ele. Afinal, há um longo processo histórico para o surgimento dos direitos fundamentais, não havendo que se falar em direito fundamental “criado por lei da noite para o dia”. Conforme ensina Sérgio Resende de Barros, “a *positivação jurídica* os *otimiza*. *Pode ser condição de eficiência. Mas não é causa de existência. A causa de existência dos direitos humanos é a própria história da humanidade*”¹²⁸.

Por fim, saliente-se que, a depender do contexto histórico em que reconhecidos, os direitos fundamentais são, comumente, divididos em gerações ou dimensões. A doutrina, em geral, prefere utilizar o termo dimensão a geração, uma vez que geração pode causar a impressão de que houve uma sucessão de direitos fundamentais, como se a geração mais nova tivesse aniquilado os direitos da geração passada, o que de fato não ocorreu. Há, em verdade, uma interdependência entre os direitos fundamentais de diversas dimensões, não importando a época em que surgiram. Portanto, nessa esteira, utilizar-se-á o vocábulo dimensão.

Em breves notas, os direitos fundamentais dividem-se nas seguintes dimensões, em conhecida classificação difundida pelo jurista tcheco Karel Vasak:

Primeira dimensão: constituída pelos direitos civis e políticos, também chamados de direitos de liberdade, os quais, para serem preservados, exigiriam uma abstenção estatal (um não-fazer, uma omissão). A preocupação essencial era com o indivíduo singularmente considerado, objetivando sua proteção em face do abuso do poder estatal. Surgiram, basicamente, na época das revoluções burguesas.

128 BARROS, Sérgio Resende de. *A difusão dos Direitos humanos fundamentais*. In: *Direitos fundamentais coletivos e difusos: questões sobre a fundamentalidade*, Richard Pae Kim, Sérgio Resende de

Segunda dimensão: é formada pelos direitos econômicos, sociais e culturais, os quais, para serem implementados, ao contrário dos direitos de primeira dimensão, exigem uma atuação positiva por parte do Estado (um fazer). Tais direitos surgiram como forma de trazer uma maior igualdade material entre os membros de uma sociedade, isto é, esses direitos não estão mais preocupados com o indivíduo isolado, mas sim com o indivíduo inserido em um contexto social, em uma comunidade. São também chamados de “*direitos de igualdade*”. Seu surgimento ocorreu com as denominadas revoluções industriais.

Terceira dimensão: é constituída pelos chamados “*direitos de solidariedade e de fraternidade*”, a exemplo do direito ao meio ambiente e do direito à paz, importando-se com o ser humano enquanto membro da humanidade. Seu surgimento ocorreu após o fim da segunda guerra mundial.

Verifica-se, portanto, que os direitos fundamentais são fruto de uma construção histórica que não pode ser ignorada. Assim, torna-se essencial conhecer a historicidade dos direitos fundamentais para que se compreenda as características do instituto estudado.

DA DEFINIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

A definição de direitos fundamentais é tarefa árdua, tendo em vista que a doutrina não é unânime acerca do tema.

Antes de definir os direitos fundamentais, convém explicar o que se entende por direitos humanos e qual a relação de um com o outro instituto.

Direitos humanos são os direitos inerentes à condição humana, isto é, são direitos inerentes a uma pessoa pelo simples fato dela existir. Visam à concretização da dignidade da pessoa humana, isto é, ao poder de autodeterminação do indivíduo e ao fato do ser humano ser encarado como um fim em si mesmo, e não como um meio para a satisfação da vontade alheia. Servem como limite ao poder estatal, formando um escudo impenetrável à vontade do Estado. Em regra, são direitos previstos em tratados e convenções internacionais, que acabaram por relativizar o rígido conceito de soberania estatal que existia outrora, a exemplo dos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948.

Quando esses direitos humanos são internalizados em um ordenamento jurídico de determinado país, geralmente por meio da *constituição*, passam a ser chamados de *direitos fundamentais*. Em outras palavras, direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos constitucionalizados.

Para Valério de Oliveira Mazzuoli¹²⁹, “*direitos fundamentais é expressão mais afeta à proteção constitucional dos direitos dos cidadãos. Ligam-se, assim, aos aspectos ou matizes constitucionais (internos) de proteção, no sentido de já se encontrarem positivados nas Constituições contemporâneas*”, ao passo que “*direitos humanos são, por sua vez, direitos inscritos (positivados) em tratados ou em costumes internacionais. Ou seja, são aqueles direitos que já ascenderam ao patamar do Direito Internacional Público.*”

Mais adiante, complementa o mencionado autor¹³⁰ afirmando que a Constituição brasileira de 1988 utilizou das expressões “*direitos fundamentais e direitos humanos*” com absoluta precisão técnica, a exemplo das previsões contidas no art. 5º, § 1º (“*as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*”) e no art. 5º, §3º (“*os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais*”).

Todavia, deve ser esclarecido que, em relação ao conteúdo, os direitos fundamentais são exatamente equivalentes aos direitos humanos (visam, em última análise, concretizar a dignidade da pessoa humana), diferenciando-se no seu âmbito de previsão: enquanto os direitos humanos são previstos em tratados internacionais, os direitos fundamentais estão constitucionalizados.

Há ainda quem diferencie os direitos fundamentais em normas formal e materialmente constitucionais. Para essa corrente, direitos fundamentais formalmente constitucionais seriam todos aqueles constantes no Título II da Constituição Federal (artigos do 5º ao 17º), independentemente do seu conteúdo. Já os direitos fundamentais materialmente

constitucionais seriam aqueles que, em seu conteúdo, efetivamente limitam o poder estatal e concretizam a dignidade da pessoa humana, sendo passíveis, portanto, de gozarem de *status* constitucional. Obviamente, a concepção do que deve ou não fazer parte de uma constituição é variável no tempo e no espaço.

De qualquer maneira, vale frisar que o rol de direitos fundamentais constantes na Constituição brasileira não é exaustivo, justamente pela previsão contida no art. 5º, §2º da CF: “*os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*”

Saliente-se que há parcela da doutrina defendendo a absoluta similitude entre direitos humanos e direitos fundamentais, ao ponto de sugerir como equivalentes as expressões “*direitos humanos fundamentais*” ou “*direitos fundamentais humanos*”, tamanhos os pontos de coincidência entre os institutos. A título de exemplificação, convém mencionar, a posição de Sérgio Resende de Barros, para quem “*não há razão por que separar direitos fundamentais e direitos humanos, colocando aqueles numa situação firme e definida e estes em situação imprecisa e insegura. (...) Ao invés da diversidade, há integração: todos os direitos humanos são fundamentais e todos os direitos fundamentais são humanos*”.¹³¹

Por fim, não há que se confundir os direitos fundamentais com os direitos humanitários, afinal, estes últimos surgiram para regular as relações específicas que emergem durante um conflito armado. Assim, ao se preservar uma escola ou um hospital de um bombardeio aéreo em uma guerra, está-se a tratar, em verdade, de direito humanitário, e não de direito fundamental. Justamente por isso é que os direitos humanitários também são chamados de Direito da Guerra e de Direito dos Conflitos Armados.

Crê-se que, com essa breve explicação, o objetivo de delimitar o que se entende por direitos fundamentais tenha sido atingido.

129 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 672.

130 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. São Paulo: Editora

131 BARROS, Sérgio Resende de. *A difusão dos Direitos humanos fundamentais*. In: *Direitos fundamentais coletivos e difusos: questões sobre a fundamentalidade*. Richard Pae Kim, Sérgio Resende de

DA DEFINIÇÃO DE REGIME JURÍDICO

Se se está a falar sobre o regime jurídico dos direitos fundamentais, além da conceituação do que são direitos fundamentais, cabe explicar o que se entende por regime jurídico.

Regime jurídico é o conjunto de normas jurídicas (portanto, de princípios e regras) que rege determinada relação jurídica. Ao se tratar do regime jurídico, o estudioso do tema pretende delimitar certa organicidade/coerência entre as normas jurídicas que regem determinada matéria. Assim, toda vez que surge uma relação jurídica, deve-se indagar quais as normas que tratarão daquele assunto ou, em linguagem mais técnica, qual o regime jurídico que *incide* sobre aquela temática.

Na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello¹³², regime jurídico é o “*sistema de princípios e normas que disciplinam e regulam um objeto do Direito*”, acrescentando ainda que, para encontrá-lo, deve-se analisar tanto o sistema normativo incidente quanto o próprio instituído analisado.

Durante muito tempo, o assunto “regime jurídico” esteve polarizado entre o direito público e o direito privado. Desta maneira, ao se indagar qual o regime jurídico de determinado instituto, o estudioso do passado frequentemente ouvia que deveria *incidir* o regime jurídico de direito público ou o regime jurídico de direito privado, como se fossem normas que se contrapunham integralmente.

É de se recordar que o regime jurídico de direito público é caracterizado (i) pela indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos e (ii) pela supremacia do interesse público sobre o privado¹³³, enquanto o regime jurídico de direito privado é caracterizado pela (i) disponibilidade do interesse e pela (ii) autonomia privada.

Ocorre que, hodiernamente, fala-se cada vez mais em uma interpenetração do regime jurídico de direito público no regime de direito privado (publicização do regime privado) e vice-versa (privatização do direito público), que praticamente impede a existência de um regime jurídico “puro” de direito público ou de direito privado.

132 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. *Natureza e regime jurídico das autarquias*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 414.

133 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 28. ed. São Paulo:

Daí a dificuldade de, hoje em dia, se afirmar com segurança que determinado instituto segue tão-somente o regime jurídico público ou privado.

Com a temática dos direitos fundamentais não é diferente: há grande dificuldade em se afirmar, com absoluta segurança, que os direitos fundamentais seguem apenas o regime jurídico público ou privado, havendo momentos tendentes a uma maior influência do direito público e outros momentos tendentes a se respeitar com maior intensidade os pilares do direito privado. Ante a dificuldade em se “encaixar” os direitos fundamentais sob a tutela única e exclusiva do direito público ou do direito privado é que é preferível afirmar que os direitos fundamentais seguem um regime jurídico próprio, tamanha é a existência de especificidades que o diferencia dos demais regimes jurídicos existentes.

AS CARACTERÍSTICAS DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Conforme afirmado no tópico precedente, não se pode afirmar que os direitos fundamentais seguem um regime jurídico *peremptório* seja de direito público ou de direito privado. O ideal é afirmar que, diante de tantas especificidades, os direitos fundamentais seguem um regime jurídico próprio que concentra características tanto do direito público quanto do direito privado, mas sem se confundir com estes.

Na lição de Vidal Serrano Nunes Júnior¹³⁴, “os direitos fundamentais constituem uma categoria jurídica e, nessa medida, apresentam traços comuns, que, demarcando um perfil essencial de todos os direitos que recebem tal adjetivação, enunciam as características básicas de seu regime jurídico”.

Desde já, convém esclarecer que esse regime jurídico dos direitos fundamentais é, ao mesmo tempo, próprio e geral, isto é, serão listadas algumas características genéricas desse regime jurídico, sem significar que na aplicação de um ou de outro direito fundamental não possa haver nuances peculiares em sua efetivação.

134 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. *A Cidadania Social na Constituição de 1988*. São Paulo: Edi-

A seguir, serão listadas algumas características que permitem identificar o mencionado regime jurídico próprio dos direitos fundamentais.

1 – *Aplicação imediata dos direitos fundamentais* – Segundo previsão expressa contida no artigo 5º, § 1º da Constituição Federal, os direitos fundamentais devem ser aplicados de maneira imediata às relações jurídicas. Isto significa que, via de regra, não é necessário se aguardar uma eventual intermediação legislativa para que os direitos fundamentais previstos na constituição sejam efetivados. Tal explicação, por mais evidente que aparente ser, ainda é fonte de polêmicas e divergências doutrinárias. Muitos ainda advogam a necessidade de lei para regulamentar a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Desta maneira, há posições antagônicas na doutrina acerca da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Exemplificativamente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho¹³⁵ entende que o artigo 5º, § 1º da Constituição Federal não pode atentar contra a *natureza das coisas*, de maneira que os direitos fundamentais somente teriam aplicação imediata caso suas normas estivessem completas na sua hipótese e no seu dispositivo. Já para Eros Roberto Grau¹³⁶, “dizer que um direito é imediatamente aplicável é afirmar que o preceito no qual inscrito é auto-suficiente, que tal preceito não reclama – porque dele independe – qualquer ato legislativo ou administrativo que anteceda a decisão na qual se consome a sua efetividade”. Não se desconhece a existência de posição doutrinária entendendo que apenas os direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos de liberdade) é que teriam sua aplicabilidade imediata (justamente por exigirem “apenas” uma omissão/abstenção estatal), sendo que os direitos fundamentais de segunda dimensão (direitos econômicos, sociais e culturais) seriam meras normas programáticas. Essa foi, inclusive, a razão mencionada para a cisão dos direitos de primeira e de segunda dimensão em dois pactos internacionais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos firmados em Nova Iorque, em 1966. Com a divisão dos direitos em dois pactos internacionais, os Estados teriam uma maior liberdade para aderirem

a um pacto e não aderirem a outro. Quicá, essa posição é fruto de percepção de que apenas os direitos fundamentais de segunda dimensão é que gerariam custo financeiro ao Estado para a sua implementação, necessitando, portanto, de lei regulamentadora. Conforme ensina Valério de Oliveira Mazzuoli¹³⁷, os direitos econômicos, sociais e culturais foram garantidos no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 convencenando-se chamar de *normas de caráter programático*, pois pressupõem a existência de recursos econômicos que não se encontram ao alcance de todos os Estados. Toda-via, no mundo fenomênico, é cediço que qualquer direito fundamental (inclusive de primeira dimensão), para ser implementado, gerará um custo financeiro ao Estado, seja direta ou indiretamente. Ademais, se a própria Carta Magna não distinguiu a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais em direitos de primeira ou segunda dimensões (art. 5º, § 1º), não caberia ao intérprete fazê-lo.

2 – *Indivisibilidade dos direitos fundamentais* – Por essa característica, os direitos fundamentais formam um todo indivisível, não podendo ser analisados de maneira isolada, cindível. Vale dizer: para que a dignidade da pessoa humana seja preservada, de nada vale a garantia dos direitos de primeira dimensão, caso os direitos de segunda e terceira dimensões estejam desprotegidos. Destarte, todos os direitos fundamentais submetem-se ao mesmo regime jurídico, isto é, tanto os direitos fundamentais de primeira quanto os de segunda e terceira dimensões são regidos, basicamente, pelo mesmo conjunto de normas jurídicas. Assim, um direito fundamental de primeira dimensão, marcado essencialmente pela necessidade de abstenção estatal, terá o mesmo regime jurídico aplicável ao direito fundamental de segunda dimensão, que é caracterizado pela exigência de ação positiva por parte do Estado. Exemplificando, tanto o direito fundamental de primeira quanto o de segunda dimensão deverão ter sua aplicação imediata, segundo dispõe o artigo 5º, § 1º da Constituição Federal. Porém, na esteira do relatado acima, vale lembrar que há quem advogue que apenas os direitos fundamentais de primeira dimensão é que teriam sua aplicabilidade imediata, diferenciando o regime jurídico dos direitos fundamentais de primeira e de segunda dimensões.

135 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Direitos Humanos Fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 100.

136 GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2007.

137 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. São Paulo: Editora

3 – *Aplicação dos direitos fundamentais tanto na relação de direito público como na relação de direito privado* - Conforme já afirmado no presente trabalho, os direitos fundamentais, historicamente, surgiram como forma de frear o abuso do poder estatal. Serviam, assim, para formar um escudo protetor do indivíduo em face do Estado. Desta maneira, sem dúvida algum, no seu nascedouro, os direitos fundamentais foram pensados para serem aplicados nas relações de direito público (relação indivíduo x Estado - eficácia vertical dos direitos fundamentais). E ainda há boa parcela da doutrina que defende a aplicação dos direitos fundamentais única e exclusivamente em face do Estado. Todavia, é cada vez mais aceito o entendimento de que os direitos fundamentais também são aplicáveis às relações privadas (indivíduo x indivíduo - eficácia horizontal dos direitos fundamentais), isto é, todos devem respeito aos direitos fundamentais, seja na relação jurídica com o Estado ou na relação jurídica com outro particular. Vale dizer: os direitos fundamentais vinculam tanto entidades públicas quanto entidades privadas. Há, inclusive, entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Observe-se:

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. (...) (RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821)

Desta maneira, os direitos fundamentais também são aplicáveis às relações de direito privado (indivíduo x indivíduo), sendo esse entendimento cada vez mais aceito atualmente.

4 – *Universalidade* - A universalidade, para os direitos fundamentais, significa que há um núcleo comum de direitos desta espécie

que são aplicáveis a qualquer pessoa em qualquer localidade, desde que ela esteja submetida à soberania brasileira (se se está a falar de direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira), independentemente do fato de ser cidadão brasileiro ou estrangeiro. Desta maneira, os direitos fundamentais são universais pois aplicáveis a qualquer pessoa, independente da sua condição de nacional ou não. Assim, o vínculo jurídico-político que une uma pessoa a determinada nação não tem tanta relevância por ocasião da garantia de direitos fundamentais mínimos a qualquer indivíduo que esteja submetido à Carta Magna brasileira, a exemplo do direito à vida. Porém, convém esclarecer que há exceções ao acima relatado, isto é, determinados direitos fundamentais não se aplicam a todas as pessoas indistintamente. Como exemplo, pode-se mencionar o direito ao voto, que não se aplica aos *conscritos* durante o período de serviço militar e nem aos estrangeiros (art. 14, §2º, CF) e os direitos trabalhistas, que se aplicam, obviamente, apenas aos trabalhadores. Em que pese essa particularidade, pode-se afirmar que os direitos fundamentais são universais no sentido de serem aplicáveis a todos que se encontram na mesma situação, respeitadas, obviamente, *clivagens* específicas (infância, mulheres, trabalhadores etc).¹³⁸

5 – *Titularidade* - Essa característica está relacionada à anterior. Se por meio da universalidade foi afirmado que os direitos fundamentais são aplicáveis a qualquer pessoa em qualquer localidade, pela titularidade tem-se a esclarecer que todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais (com as ressalvas mencionadas no item precedente). Desde logo, convém fazer um alerta: dizer que todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais não pode levar o intérprete a confundir os institutos da titularidade com os da capacidade de direito e de fato. Nesse sentido, capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, ao passo que capacidade de fato é a aptidão para exercer, por si só, esses direitos e obrigações. Desta maneira, a título de exemplo, pode-se afirmar que uma criança, indubitavelmente, é titular de direitos fundamentais que, caso ofendidos, podem ensejar a reparação por parte do ofensor, mediante ação judicial. No exemplo mencionado, o fato da criança ser representada no processo judicial pelos seus genitores não retira dela a titularidade do direito fundamental.

6 - *Irrenunciabilidade* - Os direitos fundamentais são inatos aos seres humanos e objetivam, em última análise, concretizar a dignidade da pessoa humana. Desta maneira, é da sua natureza não poderem ser renunciados, sob pena de perderem toda a sua essência. A renúncia a um direito fundamental traz em si um caráter de perenidade, que não se confunde com o não exercício de um direito fundamental, este de caráter temporário. Desta maneira, não é possível a renúncia a um direito fundamental, mas é possível que, em um caso concreto, um direito fundamental ceda em favor de outro direito fundamental igualmente aplicável no mesmo caso, sem que esta cessão configure que o seu titular está “abrindo mão de um direito fundamental para sempre”. Trata-se, apenas, de uma técnica de harmonização de mais de um direito fundamental incidente sobre o mesmo caso concreto.

7 - *Restrição, em regra, por meio de lei expressa* - Em geral, a restrição a um direito fundamental deve vir expressa por meio de lei, até mesmo por imposição do mandamento constitucional previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”). Todavia, isso não significa que em determinadas hipóteses, ante a ausência de previsão legal expressa, um direito fundamental quando em cotejo com outro direito fundamental incidente sobre o mesmo caso não possa ser restringido por meio da técnica da ponderação/proporcionalidade (com a sua subdivisão em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Destarte, a existência de uma lei prevendo alguma restrição a um direito fundamental não pode ser tomada como instrumento único para essa finalidade, havendo a possibilidade de cotejo de direitos fundamentais incidentes sobre o mesmo caso concreto, que poderá levar à aplicação da técnica da ponderação. Para Canotilho¹³⁹, há, basicamente, três formas admitidas de restrições aos direitos fundamentais: (i) restrições diretamente estabelecidas pelas próprias normas constitucionais; (ii) restrições estabelecidas por lei mediante autorização expressa da constituição; e (iii) restrições não expressamente autorizadas pela constituição, mas que são admitidas pela necessidade de resolução de conflitos de direitos.

139 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e teoria da constituição*, 7ª ed.,

8 - *Direitos fundamentais como princípios* - Modernamente, os princípios são considerados espécies de normas jurídicas, ao lado das regras. Assim, não vige mais o antigo entendimento de que os princípios jurídicos tinham apenas uma função de norte interpretativo, somente sendo utilizados em caso de ausência de lei regulamentadora de uma dada matéria, a exemplo do disposto no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”). Em linhas gerais, princípio consiste na positividade de um valor. Na lição de Robert Alexy:¹⁴⁰ “princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas”. Tendo em vista que os princípios devem ser satisfeitos na maior medida possível, eventual colisão entre eles se resolve pelo método da ponderação, sem a invalidação permanente de um em detrimento do outro. Já as regras consistem na concretização de um princípio jurídico, sendo aplicadas pelo método do “tudo-ou-nada”, isto é, são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Ronald Dworkin acentua que “as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.”¹⁴¹ Para Robert Alexy “se uma regra vale, então deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível”.¹⁴² Assim, um conflito entre regras se resolve pelo método da *subsunção*, ou seja, a situação fática sofre a consequência jurídica tipificada em uma certa regra, que é aplicável àquele caso concreto, em detrimento de outras regras que, aparentemente, também regulariam o fato analisado.¹⁴³ Nesse contexto, dizer que os direitos fundamentais possuem natureza *principlológica* significa afir-

140 ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 90.

141 DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. Tradução e notas de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39.

142 ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 91.

143 Não se desconhece que o próprio Robert Alexy admitiu, ainda que de forma sutil em sua obra, a ponderação entre regras, sob o argumento de que, tendo em vista que toda regra concretiza um princípio e sendo este um valor, o conflito entre regras também poderia caracterizar um conflito de valores, solucionável pela via da ponderação (ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamen-*

mar que eles são aplicados na maior medida possível, mediante a técnica da ponderação com eventuais outros direitos fundamentais cabíveis ao caso concreto. Assim, eventual conflito entre direitos fundamentais não faz com que um direito seja “invalidado” em prol do outro, mas sim que um direito fundamental ceda em favor de outro em determinada situação. Destarte, a natureza principiológica dos direitos fundamentais também é uma característica inerente ao seu regime jurídico próprio.

Crê-se que, com as características mencionadas acima, tenha-se conferido uma noção acerca das peculiaridades do regime jurídico próprio dos direitos fundamentais.

Evidentemente, há outras características inerentes aos direitos fundamentais que não foram aqui elencadas, seja por impossibilidade física de se elencar todas as peculiaridades em um artigo jurídico, seja pelo fato de que diversos autores promovem diversas classificações, sem que se possa afirmar que uma esteja correta em detrimento de outra. É cediço que, academicamente, a classificação de uma matéria se divide em útil ou inútil, e não em certa ou errada.

CONCLUSÃO

O presente artigo objetivou demonstrar certas características dos direitos fundamentais que permitem afirmar que tais direitos estão submetidos a um regime jurídico próprio.

Foram apresentados os conceitos de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanitários, além da definição de regime jurídico e os alicerces tanto do direito público quanto do direito privado.

Todavia, não basta saber o que são os direitos fundamentais, sendo imperioso que se saiba igualmente quando e de qual maneira eles são aplicáveis.

Desta maneira, foram listadas certas características dos direitos fundamentais que tornam o seu regime jurídico peculiar, sem se confundir com o regime jurídico de direito público ou de direito privado.

Ademais, o artigo objetivou analisar as características gerais desse regime jurídico próprio, valendo ressaltar que determinados direitos fundamentais, ao serem aplicados em um caso concreto, podem apresentar nuances específicas que destoam do regime genérico.

Acredita-se que o presente artigo atingiu a sua finalidade: fomentar um debate acerca das principais características informadoras dos direitos fundamentais, que permitam distingui-los de outras espécies de direitos.

Com isso, os direitos fundamentais passam a ser analisados em sua aplicação prática, aproximando-os dos seus titulares, a fim de que a dignidade da pessoa humana possa, enfim, ser concretizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2011.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 28ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
- _____, Celso Antonio. *Natureza e regime jurídico das autarquias*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968.
- BARROS, Sérgio Resende de. *A difusão dos Direitos humanos fundamentais*. In: Direitos fundamentais coletivos e difusos: questões sobre a fundamentalidade. Richard Pae Kim, Sérgio Resende de Barros, Fausto Kozo Matsumoto Kosaka (coordenadores). São Paulo: Editora Verbatim, 2012.
- CAMARGO, Marcelo Novelino (Org.). *Leituras complementares de constitucional – Direitos Fundamentais*. Salvador: Jus Podivm, 2007.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e teoria da constituição*. 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2016.
- CUNHA JÚNIOR, Dirley da. PAMPLONA FILHO, Rodolfo (Orgs). *Temas de Teoria da Constituição e direitos fundamentais*. Salvador: Jus Podivm, 2007.
- DWORKIN, Ronald. *Levando os direitos a sério*. Tradução e notas de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Direitos Humanos Fundamentais*. São Paulo: Saraiva, 2006.
- GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2007.
- MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
- NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. *A Cidadania Social na Constituição de 1988*. São Paulo: Editora Verbatim, 2009.

Coordenação:
Fátima Aparecida Kian

DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS

André Forato Anê

Carlos Alberto de Assis Santos

Débora Perilo Scherwitz

Fátima Aparecida Kian

Frederico Afonso Izidoro

Jair Ferreira da Silva

Luis Carlos Pileggi Costa

Marcelo José Grimone

Marcos Antonio Silva

Milena Fernandes Gallardo Anê

Natacha Slusarenko da Silva

Rafael Adolfo Percovich Cisneros

Vander Ferreira de Andrade

Wilson José Vinci Júnior

DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS

EDITORA NELPA

Em direitos humanos – mais exatamente em direitos fundamentais – é preferível, na constante busca de sua efetivação, pecar pelo excesso a pecar pela omissão. Evidentemente, os direitos fundamentais não são solução para todos os males da humanidade. Ainda assim representam, quando efetivados, um dos mais valiosos instrumentos de progresso do ser humano.

Integrante do patrimônio comum da humanidade, esse núcleo de direitos está em constante aperfeiçoamento no âmbito internacional, coexistindo com a Norma Constitucional das ordens jurídicas nacionais. Em âmbito interno, é, ao lado das noções de senates e de justa medida, a mais importante ferramenta de aplicação do direito constituindo o amálgama entre as normas e os fatos.

Esta obra foi elaborada especialmente para oferecer ao leitor uma visão panorâmica e abrangente dos direitos humanos fundamentais, sendo de grande valia aos estudiosos e profissionais do direito.

Organizada como coletânea de artigos, é mais um trabalho da já conhecida coleção, dando continuidade à contribuição para a aplicação da legislação brasileira e dos tratados internacionais de que o Brasil é signatário – notadamente em matéria de direitos humanos e de tutela das minorias.

Com linguagem simples e didática e com espírito inovador, a obra é fruto da larga experiência dos autores na docência superior e no serviço público. A Editora Nelpa espera, assim, que o livro mantenha a receptividade conquistada pela coleção, e seja mais um instrumento prático de estudo e de consulta diários.

Editora Nelpa

ISBN 978-85-8020-562-6



EDITORA NELPA